

0020603-27.2010.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... de drogas, indicam que os réus fazem do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, ou seja, dedicam-se à atividade criminosa, não podendo ser considerados como pequenos traficantes, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0020603-27.2010.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0020603-27.2010.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Pasquali Filho e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS e CARLOS PASQUALI FILHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e foram denunciados, juntamente com o acusado NEDISON DOS SANTOS RIBEIRO como incurso no artigo 333, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no mês de outubro de 2010, nesta cidade, Jailson e Carlos associaram-se para o fim de para praticar, reiteradamente, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que, no dia 9 de novembro de 2010, por volta de 16h30, na rua Professor Antonio Jesus com a rua Maria Pacheco, nesta cidade, os acusados Jailson e Carlos traziam consigo, para fins de tráfico, 12 tijolos e mais 165 porções de maconha, uma porção a granel de cocaína, diversas pedras a granel e mais 75 pedras de crack, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foram também apreendidos sacolas plásticas e várias cápsulas plásticas vazias,

sacolas plásticas normalmente usadas para embalar drogas, sendo apreendido, com o acusado Carlos, a quantia de R\$265,00 e, com o acusado Jailson, a quantia de R\$45,00.

Consta, por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas no parágrafo anterior, os acusados Jailson e Carlos, juntamente com o corréu Nedison, ofereceram vantagem indevida a funcionários públicos, a fim de que omitissem ato de ofício.

Os réus foram notificados e ofereceram defesa preliminar.

Recebida a denúncia (fls. 134), os réus foram citados.

Durante a instrução, os acusados foram interrogados, e foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Intimadas as partes para manifestarem-se acerca do interesse na realização de novos interrogatórios dos acusados, somente o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade.

Encerrada a instrução, as partes ofereceram memoriais.

O Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

Declarada a nulidade da audiência realizada às fls. 442 apenas quanto a corréu Nedison, que se encontrava indefeso naquela oportunidade em razão da suspensão de seu patrono no momento da realização daquele ato, os autos foram desmembrados em relação a ele (fls. 485).

Diante das declarações médicas apresentadas pelas Defesas dos acusados Carlos e Jailson, justificando suas ausências à audiência realizada às fls. 442, foi designado novo ato para a realização de seus interrogatórios.

Pela Defesa do acusado Carlos foi manifestado o desinteresse na realização de novo interrogatório.

Às fls. 530, o acusado Jailson foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público reiterou seus memoriais já apresentados anteriormente.

A Defesa do acusado Carlos, em memoriais, aduziu, preliminarmente, inépcia da denúncia e inobservância do rito adequado. No mérito, pugnou por sua absolvição por todos os crimes a ele imputados, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa especial de redução de pena quanto ao delito de tráfico de drogas.

A Defesa do acusado Jailson, por sua vez, pugnou por sua absolvição quanto a todos os crimes, por falta de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar de inépcia da denúncia arguida pela Defesa do acusado Carlos deve ser rejeitada.

A inicial é perfeita, inexistindo mácula a ser reconhecida.

A denúncia descreve os fatos relativos aos réus, possibilitando, assim, o irrestrito exercício da ampla defesa.

Como cediço, somente quando se trate de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração dos fatos principais é que a denúncia pode ser considerada inepta, caso não possa ser suprida por outros elementos de prova, antes da sentença final, o que não ocorre nos autos.

Cumprе ainda salientar que não é necessária, para a caracterização dos crimes de autoria conjunta ou coletiva, que conste na denúncia, de maneira pormenorizada e individualizada, a participação de cada um dos acusados, bastando para tanto unidade de propósito ou de desígnios nas ações desenvolvidas, propiciando, desta forma, adequação típica.

Sobre o tema as seguintes decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Não é inepta a denúncia que, ao imputar a prática de delito societário aos acusados, deixa de individualizar pormenorizadamente a conduta de cada um deles, mas fornece dados suficientes à admissibilidade da acusação, permitindo a adequação típica. (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso)." (STJ - RHC 17523-PE - 5ª T. - Rel. Min. Felix Fischer - DJU 22.08.2005 - p. 305).

"Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta satisfaz todos os requisitos do art. 41 do CPP, sendo mister a elucidação dos fatos em tese delituosos descritos na vestibular acusatória à luz do contraditório e da ampla defesa, durante o regular curso da instrução criminal." (STJ - RHC 17077-RS - 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 01.07.2005 - p. 564).

Conforme leciona MIRABETE:

"O crime de autoria coletiva não obriga a denúncia a pormenorizar o envolvimento de cada réu, bastando a narrativa genérica do delito, sem que tolha, evidentemente, o exercício da defesa" (in "Código de Processo Penal Interpretado" - 2ª. ed. - p. 89).

Outrossim, a preliminar relativa ao rito processual adotado, também suscitada pela Defesa de Carlos, não merece guarida.

Inicialmente, observe-se que a Defesa, desde a primeira manifestação nos autos, nada alegou quanto ao rito processual adotado e em nenhum outro momento dos autos, anteriormente aos memoriais, arguiu qualquer nulidade, não podendo, somente agora, beneficiar-se de sua própria torpeza.

Veja que somente a Defesa do corréu Nedison (em razão de quem os autos foram posteriormente desmembrados), em sua defesa preliminar, requereu o desmembramento dos autos, manifestando-se contrariamente ao rito adotado (fls. 126/129).

O pedido feito pela Defesa de Nedison foi indeferido em audiência (fls. 143), ressaltando-se que o rito especial deve preponderar sobre o rito ordinário, além de ser aquele mais benéfico ao réu, pois a denúncia somente seria recebida após o oferecimento de defesa preliminar.

Veja-se que, nessa ocasião, a Defesa de Carlos, presente à audiência, não se insurgiu contra o rito processual.

Saliente-se, ainda, que, ouvidas todas as testemunhas arroladas pelas partes, oportunizou-se novo interrogatório dos acusados, beneficiando-se a amplitude de defesa.

Entretanto, a Defesa de Carlos manifestou desinteresse na realização deste novo ato (fls. 528), sem ter demonstrado qualquer insurgência, também neste aspecto, com relação ao rito adotado.

Acerca do tema, confira-se:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CONCURSO MATERIAL. CRIMES COM RITOS DISTINTOS. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI DE DROGAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA OBSERVADA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica.

2. Em obediência aos princípios constitucionais que informam o processo penal, em especial o do contraditório e o da ampla defesa, no caso de concurso de crimes - conexos ou continentes - com procedimentos diversos, deve ser adotado o procedimento em que seja prevista a maior possibilidade de defesa ao acusado.

3. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

4. Embora, no rito ordinário, a defesa possa arrolar até 8 (oito) testemunhas, enquanto que, no rito da Lei de Drogas, até o número de 5 (cinco), não há constrangimento ilegal na adoção do procedimento previsto na Lei n. 11.343/2006 quando verificado que, na audiência de instrução e julgamento, a defesa quis ouvir apenas 2 de suas testemunhas.

5. Não há constrangimento ilegal no procedimento adotado pelo Juiz singular, quando verificado que, tanto na resposta à acusação quanto na audiência de instrução e julgamento, a defesa quedou-se inerte, nada falando sobre o rito aplicado.

6. Em que pese tenha sido adotado o procedimento da Lei de Drogas, a Corte estadual salientou que o interrogatório do paciente ocorreu apenas depois da oitiva de todas as testemunhas, o que possibilita uma maior amplitude de defesa, já que permite que o acusado rebata todos os argumentos e todas as provas que foram produzidas na instrução.

7. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n.

11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

8. No caso, tendo o Juiz sentenciante apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o paciente era integrante, mostra-se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, como pretendido.

9. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 453.000/RS (DJ 3/10/2013), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, declarou a constitucionalidade da aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais.

10. Habeas corpus não conhecido." (HC 217.972/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 26/11/2013)

No mérito, a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/19 pelo auto de constatação de fls. 20/21, pelas fotografias de fls. 22/23, pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 148/149 e 150, bem como pela prova oral produzida em Juízo e demais elementos probatórios constantes dos autos.

A autoria é certa quando ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados Jailson e Carlos e, quanto ao crime de corrupção ativa, somente em relação ao corréu Carlos.

Interrogado em Juízo, o acusado Carlos negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Disse que o veículo descrito na denúncia era de seu tio e este pediu que levasse o automóvel para que o vidro, que estava quebrado, fosse consertado. Contou que levou o veículo ao conserto, deixando-o na oficina, e o buscou no dia seguinte, o que ocorreu cerca de dois ou três dias antes da data em que se deram os fatos. Disse que, ao retirar o veículo do conserto, levou-o para sua casa e ali ele permaneceu. Alegou que, na data dos fatos, o acusado Jailson pediu que o levasse até a casa de sua namorada e, no momento em que dava carona a Jailson, foram abordados. Disse que os policiais abriram o porta-malas do veículo e mostraram as drogas, mas alegou que estas não eram de sua propriedade e que não as havia visto antes. Contou que o corréu Jailson estava consigo no veículo, mas os entorpecentes também não pertenciam a ele. Negou ter oferecido dinheiro aos policiais e alegou ter ligado para o acusado Nedison, a fim de que ele fosse ao local da abordagem buscar o veículo apreendido, e não soube por que motivo Nedison levou dinheiro ao local. Disse que não viu qualquer dinheiro, pois estava na viatura. Alegou que, após retirar o carro do conserto, sua mãe não permitiu que o usasse novamente, pois não era habilitado, tendo somente usado na data dos fatos, porque o acusado Jailson era habilitado. Contou que não abriu o porta-malas quando seu tio lhe entregou o carro, nem após retirar o veículo da oficina. Alegou que os policiais os haviam abordado momentos antes, para questionar sobre a placa do automóvel, e logo após, ao parar em um semáforo, novamente eles os abordaram. Disse que consigo havia somente a quantia de R\$200,00, oriundos de seu trabalho. Contou que o acusado Jailson não portava mochila quando embarcou no veículo e não abriu o porta-malas. Reinterrogado ao final da instrução, o acusado Jailson negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Disse que mantinha relacionamento com a prima do corréu Carlos e, por isso, o conheceu. Contou que iria sair a prima de Carlos, mas recebeu ligação deste, dizendo que ele havia comprado um veículo de seu tio, mas ele estava com o para-brisa quebrado e lhe pediu ajuda para levar o carro ao conserto, pois

ele não era habilitado. Alegou que já iria ao centro da cidade e concordou em ajudá-lo. Contou que estava em sua casa, auxiliando sua mãe para colocar para dentro do imóvel materiais de construção, quando Carlos lá chegou e, então, saiu com ele. Disse que, apesar de Carlos pedir seu auxílio por não ser habilitado, ele mesmo conduziu o veículo, dizendo que se fossem parados, sua habilitação poderia ser apresentada. Disse que, no caminho, foram abordados por policiais e, em dado momento, um policial o conteve, colocando-o na viatura. Contou que ouviu um policial dizer que havia achado algo, mas não soube o que era, e depois os policiais disseram ter localizado drogas no carro, mas nada viu sendo encontrado. Alegou que não ofereceu dinheiro aos policiais e disse que, após um tempo de abordagem, foi colocado em viatura separada de Carlos. Disse que, após certo tempo, Nedison chegou ao local e também foi detido e colocado na viatura em que estava, tendo sabido por Nedison que Carlos, seu cunhado, havia pedido que ele fosse ao local, mas não soube por que motivo. Contou que o veículo de Carlos era um Fox e estava com o para-brisa quebrado.

E em que pese a negativa apresentada pelos réus, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos acusados, bem como pela dinâmica dos fatos, evidencia-se a realização do tráfico de drogas por eles. Além disso, sua versão fornecida em Juízo não é crível em face do restante das provas produzidas durante o processo. A testemunha policial militar Alexandre Leonardo Pinto, ouvida por carta precatória, relatou que realizava patrulhamento quando realizou a abordagem de dois indivíduos que estavam em um veículo em movimento. Narrou que, em busca pessoal, com ambos foi localizada quantia em dinheiro e, em busca no veículo, foi encontrada, no porta-malas, grande quantidade de entorpecentes armazenados em uma mochila preta e em vários sacos plásticos. Disse que, informalmente, os indivíduos alegaram ser ladrões de caixa eletrônico, mas que teriam assumido uma "boca de tráfico". Declarou que o indivíduo que conduzia o veículo ofereceu a quantia de vinte mil reais para ser liberado e ligou para o cunhado dele, que compareceu ao local com quase cinco mil reais e também foi detido. Não recordou o nome das pessoas abordadas. Disse que não viu nenhum dos indivíduos mexer no porta-malas do veículo, cuja propriedade não recordou ter sido apurada. Declarou que não conhecia os réus anteriormente aos fatos e não soube que versão eles apresentaram à Autoridade Policial. Relatou que não foi localizada anotação junto às drogas apreendidas.

A testemunha policial militar Fernando Henrique Fabião, ouvida por carta precatória, narrou que realizava patrulhamento quando deparou-se com um veículo Fox, de cor cinza, ocupado por dois indivíduos, que demonstraram desconforto na presença da viatura, sendo então abordados. Declarou que, feita a busca pessoal, com os acusados foi localizado dinheiro. Relatou que o policial Alexandre realizou busca e encontrou, no porta-malas do veículo, grande quantidade de drogas embalada em sacos plásticos e em uma mochila, além de cápsulas utilizadas para o emalo de drogas. Disse que, questionados, os acusados disseram ser gerentes de um ponto de tráfico próximo e que estariam trazendo a droga da cidade de Santos, além de dizer que praticavam roubos a caixas eletrônicos, mas estavam ganhando dinheiro com o tráfico. Relatou que um dos acusados ofereceu a quantia de vinte mil reais para que eles fossem libertados e telefonou para outra pessoa, que disse ser seu cunhado. Narrou que, pouco tempo depois, esta pessoa foi ao local da abordagem em uma motocicleta, portando a quantia aproximada de cinco mil reais, dizendo que se destinaria a liberar seus amigos e que posteriormente ele traria o resto do dinheiro. Disse que, quando da chegada deste terceiro indivíduo, os demais estavam detidos ainda fora da viatura, mas aquele não manteve contato pessoal com os outros dois acusados antes da entrega do dinheiro. Não recordou o nome dos acusados e não recordou se o dinheiro foi oferecido pelo motorista ou pelo passageiro do veículo. Disse que não conhecia os réus anteriormente e não recordou se a propriedade do veículo foi averiguada.

A testemunha Andressa Duarte Scuenher Bastos, arrolada pela Defesa de Jailson, ouvida por carta precatória, disse desconhecer os fatos e os acusados.

A testemunha Valter Nascimento, arrolada pela defesa de Jailson, não presenciou os fatos. Disse que estava conversando com Jailson minutos antes de ele sair de carro

com Carlos. Soube por Jailson que ele iria sair com a prima de Carlos, mostrando que tinha dinheiro em sua carteira, e que ele estaria aguardando Carlos buscá-lo de carro. Disse que essa conversa ocorreu entre 11 e 12 horas na data dos fatos e viu Jailson embarcar no veículo de Carlos, sendo que ele nada portava. Declarou desconhecer envolvimento de Jailson com drogas. Contou que não conversou com Carlos, a quem conhecia somente de vista, mas soube que Carlos daria carona para Jailson até um motel, pois a motocicleta de Jailson estava com problemas. Disse que esta conversa ocorreu em local próximo à sua residência, na Rua João Serrano.

A testemunha Dário Lucas da Silva, arrolada pela defesa de Jailson, disse ser casado com a irmã de Jailson e não presenciou os fatos. Contou que viu o momento em que o acusado saiu de sua casa, na data dos fatos, e viu que ele não portava nenhuma mochila ou sacola. Disse ter sabido pelo acusado que ele iria ver a namorada naquela data e que esta seria prima da pessoa com quem ele iria sair.

A testemunha Antonia Esquerdo Lemos, arrolada pela defesa de Carlos, disse que não presenciou os fatos e declarou que o acusado não possui envolvimento com drogas. No mais, teceu comentários acerca de sua personalidade.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa dos acusados quanto ao delito de tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

A palavra dos policiais que, de maneira segura, uniforme e convincente, descreveu com detalhes de que forma ocorreu a abordagem dos acusados e a apreensão das drogas no veículo, não restou abalada.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2- T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).
No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.
2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).
Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).
3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).
4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.
5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente,

como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se

dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço das Defesas em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles. As testemunhas policiais bem esclareceram em Juízo a dinâmica de toda a ação policial, relatando que realizaram a abordagem dos acusados, que estavam em um veículo em movimento e, feita a busca neste automóvel, encontraram grande quantidade de entorpecentes em mochila e sacos plásticos.

Acrescentou a testemunha policial Fernando que a abordagem ocorreu diante da conduta demonstrada pelos acusados na presença da equipe policial. Afirmaram que os réus, quando indagados sobre os fatos, admitiram, informalmente, a prática do tráfico de drogas.

Frise-se que os depoimentos dos policiais militares, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial e a localização dos entorpecentes, e encontram-se em verdadeira consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Observe-se que a presença dos acusados Jailson e Carlos no interior do veículo restou incontroversa nos autos, pois foi, inclusive, por eles admitida.

De outro lado, suas negativas de que as drogas fossem de sua propriedade e suas versões de que sequer sabiam da existência delas não encontraram respaldo em nenhum outro elemento de prova amealhado.

As testemunhas arroladas pelas Defesas de Jailson e de Carlos não presenciaram os fatos.

A testemunha Valter declarou que, naquela data em que o acusado foi detido, havia encontrado o acusado Jailson e que este lhe disse estar aguardando Carlos, que daria uma carona a ele até um motel, para onde iria com a prima de Carlos. Disse ter visto Carlos chegando ao local e que viu Jailson embarcando no veículo, sem nada portar consigo. Declarou Valter que esta conversa ocorreu por volta de 11 horas ao meio-dia na data dos fatos.

A testemunha Dário prestou declarações no mesmo sentido, dizendo ter sabido por Jailson que ele se encontraria com a namorada naquela data, e que esta era prima da pessoa com quem ele iria sair. Disse que Jailson não estava portando nada naquele momento.

Ocorre que os relatos apresentados pelas testemunhas Valter e Dário em nada abalaram os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus.

Por um lado, veja-se que as testemunhas Valter e Dário disseram ter visto os réus antes do horário em que os fatos ocorreram e, portanto, sem que tenham as testemunhas estado ao lado dos réus até o momento da abordagem, ocorrida por volta de 16h30min naquela data, seus testemunhos não são suficientes para demonstrar que os acusados não estavam trazendo consigo a grande quantidade de drogas apreendida pelos policiais.

De outra banda, deve-se ressaltar que os acusados não apresentaram qualquer versão plausível sobre as drogas encontradas no veículo e suas narrativas sobre o motivo de estarem juntos no veículo e sobre o local para onde iriam são absolutamente contraditórias entre si, além de sequer coincidirem com os relatos das testemunhas Valter e Dário.

Jailson, ao ser interrogado, disse que estava em sua casa, auxiliando sua mãe, quando o corréu Carlos lá passou para buscá-lo de carro, sequer mencionando ter conversado com a testemunha Valter naquela data, ao contrário do que foi por esta declarado, que afirmou ter conversado com Jailson e ter visto o momento em que ele saiu com Carlos de carro.

Note-se que, ao contrário do que disseram as testemunhas Valter e Dário, o próprio acusado Jailson disse que Carlos foi buscá-lo a fim de levarem o veículo ao conserto.

Veja-se que Jailson alegou, inclusive, que o para-brisa do automóvel estava

quebrado.

Contudo, o laudo da perícia realizada no veículo apreendido em poder dos acusados não constatou qualquer dano aos vidros do automóvel (fls. 217/221).

Além disso, Carlos, em seu interrogatório, forneceu versão absolutamente diversa daquela apresentada por Jailson, pois alegou que já havia levado o veículo para o conserto do vidro quebrado e que havia buscado o automóvel na oficina cerca de dois a três dias antes da data em que foram abordados.

Ainda, disse Carlos que, naquela data, estava com Jailson no carro, pois este havia pedido uma carona à casa da namorada dele.

As versões apresentadas pelos acusados Jailson e Carlos, além de não se mostrarem críveis, restaram, portanto, absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que suas versões sobreponham-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e localizaram as drogas e demais petrechos relacionados ao tráfico de drogas, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais e as diligências realizadas no curso da ação penal, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que os réus são, de fato, traficantes.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, evidencia-se, pois, a realização do tráfico de drogas pelos acusados.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que os réus estariam sendo acusados injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Em arremate, a intenção mercantilista dos réus deriva da grande quantidade de drogas e demais petrechos apreendidos. De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Outrossim, diante de todos os elementos coligidos aos autos, especialmente dos depoimentos das testemunhas policiais civis, de rigor reconhecer que ambos os réus estavam realizando em conjunto a prática do tráfico das drogas que foram apreendidas e, portanto, forçoso reconhecer-se que todas drogas apreendidas pertenciam a ambos os acusados.

De outro lado, quanto ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, não há prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório que possa embasar um decreto condenatório.

Não restou demonstrado que os réus efetivamente estavam associados entre si, organizando-se previamente para a prática do delito de tráfico de drogas. Não há demonstração suficiente do pacto associativo entre eles.

Veja-se que há nos autos apenas a versão informal que teria sido apresentada pelos acusados às testemunhas policiais no momento da abordagem, sem que haja qualquer outro esclarecimento sobre a efetiva associação de ambos para a prática do tráfico de drogas.

Portanto, não há prova suficiente sobre o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser os acusados absolvidos desta imputação, pois, como se sabe, a dúvida sempre deve ser resolvida em favor dos réus.

Finalmente, também restou demonstrada a prática do crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, porém apenas pelo acusado Carlos.

Como já exposto, as versões apresentadas pelos réus Jailson e Carlos mostraram-se incoerentes e também inverossímeis quanto ao crime de tráfico de drogas e o mesmo se pode afirmar quanto ao relato de Carlos relativo ao delito de corrupção ativa. Carlos, ao expor sua narrativa sobre este delito, disse ter ligado para Nedison a fim de que este fosse ao local da abordagem para buscar o veículo apreendido, sem saber por que motivo ele levou dinheiro consigo.

Jailson, por sua vez, disse somente ter visto Nedison chegando ao local dos fatos,

sabendo por este que Carlos, cunhado dele, havia pedido que ele ali comparecesse, mas não soube por que razão.

Veja-se que Nedison, em razão de quem foram os autos desmembrados, foi interrogado em Juízo, relatando ter recebido ligação de Carlos pedindo algum valor em dinheiro e falando algo relativo ao carro e, por estar trabalhando em local próximo àquele em que estava Carlos, decidiu ali comparecer, levando a quantia de R\$4.920,00 em dinheiro, que estava consigo e que era proveniente de vendas de itens de sua empresa.

Entretanto, infere-se dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que, após a abordagem e o encontro da enorme quantidade de drogas no veículo em que estavam Jailson e Carlos, um destes ofereceu a quantia de vinte mil reais para ser libertado e efetuou ligação para terceira pessoa, que disse ser seu cunhado. Asseveraram que, logo após, esta terceira pessoa realmente foi ao local da abordagem, portando cinco mil reais, portanto vultosa quantia em dinheiro, sendo também detido.

O valor levado ao local da abordagem foi efetivamente apreendido, conforme se observa às fls. 15/19, sendo inconteste a materialidade do crime.

Em que pese as testemunhas policiais não tenham conseguido indicar qual dos acusados efetivamente ofereceu dinheiro para ser libertado, verifica-se de suas declarações que o indivíduo referiu-se à terceira pessoa como sendo seu cunhado, o que, diante das próprias narrativas dos acusados, somadas aos demais elementos de prova constantes nos autos, traz a certeza de que se referiam ao corréu Carlos. Os depoimentos dos agentes de segurança devem ser admitidos como subsídio de persuasão do juiz, já que o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular, conforme já pacificado na doutrina e jurisprudência, precipuamente nos casos de crime de corrupção ativa, em que a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente e do funcionário a quem foi oferecida a gratificação.

Quanto ao elemento subjetivo, o crime de corrupção ativa exige, além do dolo genérico, consistente na vontade de oferecer ou prometer a vantagem, o elemento subjetivo do tipo (dolo específico, para a doutrina tradicional), referente ao especial fim de agir do agente (para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício).

No caso em tela, não restam dúvidas de que o acusado Carlos, ao oferecer dinheiro aos policiais militares para que estes deixassem de cumprir seu dever de ofício, ciente de estar oferecendo uma vantagem indevida, agiu de forma livre e consciente para a consecução do delito, tendo domínio do fato e sabedoria sobre a contrariedade à ordem jurídica.

De outro lado, não há prova suficiente nos autos que indique ter Jailson concorrido para a prática deste delito.

Veja-se que, embora a testemunha policial Fernando tenha relatado que a vantagem oferecida se destinaria à libertação de ambos os abordados, é certo que ambos os policiais narraram que apenas um dos réus perfez a conduta de oferecer-lhes o dinheiro.

Narraram as testemunhas que apenas um dos indivíduos detidos no veículo - que do contexto probatório depreende-se ser o acusado Carlos - ofereceu a eles uma vultosa quantia a fim de que omitissem ato de ofício, não sendo possível afirmar-se que o corréu Jailson, embora pudesse ser beneficiado de eventual omissão do ato de ofício, tenha participou desta ação criminosa.

Diante do cotejo probatório trazido aos autos, de rigor a condenação dos acusados Carlos e Jailson pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e apenas do acusado Carlos pelo crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação exposta.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

1. Quanto ao delito de tráfico de drogas:

Diante da natureza e da variedade (cocaína, crack e maconha) de drogas apreendidas com os acusados, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade dos réus, pois não se tratam de pequenos traficantes, mas sim de um grandes disseminadores dos entorpecentes, justifica-se, portanto, o aumento da pena em 1/6. Assim, fixo a

pena-base, a cada acusado, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas em relação ao acusado Jailson.

Entretanto, verifica-se dos autos que o corréu Carlos era reincidente, conforme certidão criminal de fls. 85, motivo pelo qual fica sua pena aumentada em 1/6 e fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo já fixado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da enorme quantidade (6,535 gramas de maconha, 513 gramas de cocaína e 785 gramas de crack) da droga apreendida. Especificamente quanto ao acusado Carlos, verifica-se ser ele, também, reincidente.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017 , PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Ademais, a elevadíssima quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, embora não tenha sido demonstrado que estivessem efetivamente associados para a prática do tráfico de drogas, indicam que os réus fazem do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, ou seja, dedicam-se à atividade criminosa, não podendo ser considerados como pequenos traficantes, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às

atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

2. Quanto ao delito previsto no artigo 333, caput, do Código Penal praticado pelo acusado Carlos:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado Carlos não é portador de maus antecedentes e não há outras razões para a elevação de sua pena-base acima do mínimo legal, que fixa fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o acusado é reincidente, na forma como já exposto, sendo de rigor o aumento de pena em 1/6, a qual resta fixada, para cada réu, em 02 (dois) anos e 04